

문1.

甲은 X건물을 소유하고 있으며, 아들인 乙이 오랫동안 X건물을 관리해 왔다. 甲이 병환으로 입원하자, 乙은 병원비 조달과 자신의 사업 자금 마련을 위하여 평소 보관하고 있던 甲의 인장과 관련 서류를 이용하여 위임장을 만든 후, 甲의 대리인이라고 하면서 X건물을 丙에게 매도하였다. 병원에서 퇴원한 甲이 이 사실을 알고 乙을 질책하자, 乙은 丙에게 X건물에 관한 소유권이전등기를 마쳐 주지 않았다. 이에 丙은 甲을 상대로, 주위적으로는 유권대리, 예비적으로는 표현대리에 의한 매매계약의 성립을 주장하며 매매계약을 원인으로 한 소유권이전등기청구의 소를 제기하였으나, 법원은 丙에게 추가적인 주장·증명을 요구하였다. 그러자 丙은 甲에 대한 청구가 기각될 것을 대비하여 乙을 상대로 「민법」 제135조의 무권대리로 인한 손해배상을 구하는 내용의 피고 추가 신청을 하였다.

< 문제 >

법원의 심리 결과 甲이 乙에게 명시적으로 X건물을 매도할 권한을 준 사실은 없지만 乙이 甲을 대신하여 X건물을 오랫동안 관리해 왔고, 건물 매도에 필요한 모든 서류를 乙이 보관하고 있던 점을 참작하여 甲에게 표현대리로 인한 계약상의 책임이 있다고 판단하였다. ① 丙의 피고 추가 신청은 적법한가, ② 법원은 이 사건에서 어떠한 판결을 선고하여야 하는가? (30점)

예비적 주장

문2.

예비적 주장

< 기초적 사실관계 >

버섯 재배업자인 乙은 버섯 판매업자인 丙과 신선도가 떨어지는 버섯을 속여 판매하기로 공모하고, 丙은 소매업자 甲에게 위 버섯을 공급하는 계약을 甲과 체결하였다. 甲은 불량 버섯에 대한 소비자들의 항의가 빗발치자 이를 확인하는 과정에서 乙과 丙이 공모하여 불법행위를 저지른 사실을 알게 되었다.

[※ 추가적 사실관계는 각각 별개임]

< 추가적 사실관계 1 >

甲은 乙과 丙을 상대로 서울중앙지방법원에 불법행위로 인한 1억 원의 손해배상 청구의 소를 제기하였다. 甲의 주소지는 인천광역시[토지관할 법원은 인천지방법원]이고, 乙의 주소지는 서울 서초구[토지관할 법원은 서울중앙지방법원]이며, 丙의 주소지는 대전광역시[토지관할 법원은 대전지방법원]이다.

- (1) 소장부분을 송달받은 丙은 甲이 서울중앙지방법원에 제기한 소가 자신에게 관할이 없는 법원에 제기된 것이므로 각하되어야 한다고 주장하였다. 법원은 어떻게 판단하여야 하는가? (「민사소송법」 제18조에 따른 불법행위지의 특별재판적은 고려하지 말 것) (20점)

< 추가적 사실관계 2>

甲이 소를 제기하기 전에 乙과 丙을 찾아가 항의하자, 乙은 피해변상조로 1억 원을 지급하기로 하면서 일단 2천만 원을 지급하였고, 나머지 8천만 원은 丙과 상의하여 추후 지급하기로 약속하였으나 이를 이행하지 않았다. 이에 甲은 乙과 丙을 상대로 “피고들은 공동하여 원고에게 1억 원을 지급하라”는 취지의 손해배상 청구의 소를 제기하였다. 법원은 乙과 丙에게 공시송달에 의하지 아니한 적법한 송달로 변론기일을 통지하였다. 乙은 변론 중에 자신이 이미 2천만 원을 변제한 사실을 주장하면서 그 증거로 변제증서를 제출하였으나, 丙은 답변서 기타 준비서면도 제출하지 않은 채 변론기일에도 출석하지 않았고 그대로 변론은 종결되었다.

- (2) 법원은 乙의 변제항변을 받아들여 “피고들은 공동하여 원고에게 8천만 원을 지급하라.”라는 판결을 선고하였다. 이러한 법원의 판결은 타당한가? (30점)

문3.

甲은 乙에게 2019. 1. 5. 1억 원을, 2019. 3. 5. 5천만 원을 각 무이자로 대여 하였으나 위 각 채권의 변제기가 도래하였음에도 불구하고 乙로부터 전혀 변제를 받지 못하고 있다고 주장하며, 乙을 상대로 위 각 대여금의 지급을 구하는 소를 제기하였다. 제1심에서 乙은 甲에 대한 5천만 원의 손해배상채권을 자동채권으로 하여 2019. 3. 5.자 대여금 5천만 원의 채권과 대등액에서 상계한다는 항변을 하였다. 제1심 법원은 심리 결과 甲의 위 각 대여금 채권이 인정된다고 판단하였고, 그중 2019. 3. 5.자 5천만 원의 대여금채권에 대해서는 乙의 상계항변이 인정된다고 판단하였다. 이에 제1심 법원은 위 대여금 1억 원에 대해서는 甲의 청구를 인용하고, 위 대여금 5천만 원에 대해서는 甲의 청구를 기각하였다. 이러한 제1심 판결 중 위 대여금 5천만 원 부분에 대해서는 乙만이 항소하였고, 위 대여금 1억 원 부분에 대해서는 甲과 乙 모두 항소하지 않았다.

< 문제 >

항소심 심리 결과 항소심 법원이 乙의 甲에 대한 손해배상채권이 존재하지 않는다고 판단한 경우, 항소심 법원은 어떤 판결을 선고하여야 하는가? (20점)

< 채점기준표 >

문1.

1. 쟁점

공동피고에 대한 청구가 법률상 서로 양립할 수 없는 관계에 있을 때 예비적 · 선택적 공동소송이 허용되는지의 여부와 예비적 · 선택적 공동소송의 경우 법원의 심판방법.

2. 예비적 공동소송의 허용여부

(1) 공동소송인의 청구나 공동소송인에 대한 청구가 법률상 양립할 수 없는 관계에 있고, 어느 것이 인용될 것인지를 쉽게 판정할 수 없을 경우, 필수적 공동소송의 규정을 준용하여 서로 모순 저촉없는 통일적인 재판을 구하는 예비적 · 선택적 공동소송이 허용됨(민소법 제70조).

(2) 예비적 · 선택적 공동소송은 소제기 당시부터는 물론이고 소송계속 중에 1심 변론종결 전까지 공동소송인이 될 당사자를 추가하는 방식으로 허용됨(민소법 제68조제1항).

(3) 사안의 경우 병이 갑을 상대로 하는 소는 대리 또는 표현대리의 성립을 전제로 이행을 청구하는 것이며, 갑에 대한 청구가 이유없어 기각될 경우(인용되지 않을 경우)에 대비하여 을에 대하여 손해배상을 청구할 필요가 있으므로 예비적 · 선택적 공동소송이 허용될 필요가 있으므로 병의 을에 대한 추가신청은 적법한 것임.

3. 법원의 심판방법 (대법원 2015.3.20. 선고 2014다75202 판결)

(1) 예비적 · 선택적 공동소송의 경우, 법원은 모든 공동소송인에 관한 청구에 대하여 판결을 하여야 함(민소법 제70조 제2항). 따라서 주위적 피고에 대한 청구가 이유있고 예비적 피고에 대한 청구가 이유 없을 때에 주위적 피고에 대한 인용판결과 함께 예비적 피고에 대한 기각판결 주문을 내어야 함.

(2) 사안의 경우 법원이 갑에게 표현대리책임이 있다고 판단하였으므로 갑에게 을의 표현대리책임을 물어 계약의 이행에 대한 병의 청구를 인용하는 판결을 하여야 하고 을에 대한 손해배상청구는 기각하는 판결을 하여야 함.

문2. (1)

1. 문제의 소재

각 당사자에 대하여 갑이 소를 제기할 수 있는 법원과 관련재판적이 문제됨

2. 각 당사자에 대한 관할법원과 소를 제기한 법원

1) 을에 대한 청구

을의 주소지인 서울 중앙지법, 의무이행지인 원고 주소지인 인천지법

2) 병에 대한 청구

병의 주소지인 대전지법, 의무이행지인 원고 주소지인 인천지법

3) 갑은 을과 병을 상대로 을의 주소지인 서울 중앙지법에 제소함.

3. 관련재판적

1) 의의

2) 공동소송에의 적용여부 (민소법 제25조 제2항)

4. 사안의 해결

갑이 을과 병이 공동불법행위를 이유로 제소한 것으로 이는 민소법 제25조 제2항의 소송의 목적이 되는 권리나 의무가 여러 사람에게 사실상 같은 원인으로 말미암아 생긴 경우에 해당하므로 관련재판적이 인정됨. 따라서 갑은 을과 병을 상대로 서울중앙지법에 제소한 것은 적법한 것이고 법원은 병의 관할위반의 항변을 배척하여야 함.

문2. (2)

1. 문제의 소재

통상공동소송에 있어서 공동소송인 독립의 원칙 그 수정원리로서 증거공통의 원칙과 주장공통의 원칙이 문제된다.

2. 통상공동소송의 의의

3. 공동소송인 독립의 원칙의 의의와 그 수정원리

(1) 의의와 수정원리의 필요성

이를 예외없이 그대로 관철할 경우 공동소송인 간에 모순,저촉되는 재판이 행해

질 우려가 있다. 즉 재판의 통일이 보장되지 않는 경우가 생기게 된다.

(2) 증거공통의 원칙의 의의

공동소송인 중 1인이 제출한 증거는 다른 공동소송인의 원용이 없더라도 다른 공동소송인에게 유리한 사실의 인정자료로 사용할 수 있다는 것,

(3) 주장공통의 원칙의 의의

공동소송인 중 1인이 다른 공동소송인에게 유리한 주장을 한 경우 그의 원용이 없더라도 다른 공동소송인에게도 그 효력이 미치는 것으로 보는 것 즉 그 다른 공동소송인도 주장한 것으로 볼 수 있다는 것,

(4) 긍정설과 부정설의 대립 및 판례의 입장(출석한 피고가 주장한 것을 불출석으로 자백간주된 피고가 주장한 것으로 볼 수 없다, 부정설)

4. 결론

판례에 의하면 법원이 을의 주장(변제항변)의 효과를 적법한 기일통지를 받고도 답변서 기타 준비서면도 제출하지 않은 채 변론기일에 불출석한 병에게까지 인정한 것은 타당하지 않다.

긍정설에 의하면 병이 비록 적법한 기일통지를 받고도 답변서 기타 준비서면도 제출하지 않은 채 변론기일에 불출석하였더라도 공동소송인 중 1인인 을의 주장과 그가 제출한 증거인 변제증서에 의하여 다른 공동소송인인 병의 변제사실을 인정한 것이므로 이는 타당한 것이다.

문3.

1. 문제의 소재

청구가 병합된 경우에 있어서 상소에 따른 확정차단효와 이심의 효력(상소불가분의 원칙)과 심판이 대상(범위), 항소의 이익, 불이익변경 금지의 원칙과 상계항변의 특수성이 문제됨

2. 청구의 병합(단순 병합)

2019.1.5.자 대여금 1억원과 2019.3.5.자 대여금 5천만원 청구의 단순병합

3. 상소불가분의 원칙과 항소의 이익, 심판의 대상

1) 상소불가분의 원칙

원판결 중 일부에 대하여 상소하더라도 그에 따른 확정차단효과와 이심의 효력은 원판결 전부에 대하여 생김, 단순병합에서 1개의 전부판결 중 일부인 5천만원 청구에 대한 판결 부분만 항소하여도 판결 전부가 확정이 차단되고 항소심으로 소송계속이 이전됨(이심됨). 항소인에게는 항소심 변론종결 전까지 항소취지를 확장할 수 있게 하고 피항소인에게는 부대항소를 제기할 수 있도록 하기 위한 것임.

2) 항소의 이익

1심판결이 단순한 청구기각이 아니라 출혈적 방어방법인 상계항변을 받아들여 갑의 5천만원에 대해 청구기각한 것이므로 을에게는 항소의 이익이 있음.

3) 원, 피고 모두 항소하지 아니한 부분은 항소심으로 이심되었다가 항소심 판결선고시에 확정되는 것으로 보는 것이 판례의 입장임(2009다35842).

4) 항소심 심판의 대상(범위)

갑의 청구 중 5천만원에 대한 기각판결(갑의 손해배상채권 5천만원에 대해 피고의 상계항변이 인정되어 갑의 이 부분 청구를 기각한 판결)부분은 을의 항소로 항소심으로 이심되고 심판의 범위에 포함됨.

4. 불이익변경 금지의 원칙과 상계항변의 특수성

1) 원칙

항소심은 당사자의 불복 신청 범위 내에서 판단할 수 있고 그 범위를 넘어서 1심판결을 당사자에게 유리 또는 불리하게 변경해서 판단하는 것이 금지됨.

2) 상계항변의 경우

* 원칙적으로 1심판결의 주문의 불리한 변경이 금지되는 것이고 판결이유의 변경이 항소인에게 더 불리하게 되더라도 무방함, 그러나 상계항변의 경우에는 그에 대한 판결이유에서의 판단에 기판력이 발생하므로 특별한 고려가 필요함.

* 판례는 1심판결이 출혈적 방어방법인 상계항변을 받아들여 원고의 청구를

기각한 후 피고만이 항소한 경우에 피고가 주장한 반대채권이 부존재한다 하더라도 이를 이유로 피고의 항소를 기각하는 것은 항소인인 피고에게 불이익하게 1심판결을 변경한 것이 된다고 함. 따라서 법원은 1심판결과 같은 이유를 달아 항소를 기각하여야 함,

5. 사안의 해결

항소심 법원이 을이 상계항변으로 주장한 손해배상채권이 존재하지 않는다는 심증을 가졌더라도 불이익변경 금지의 원칙에 따라 위 채권이 존재하지 않는다는 이유로 항소를 기각해서는 안 되고 1심판결과 같은 이유를 달아 항소를 기각하여야 한다.